

1500401-52.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... nos autos. 3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500401-52.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500401-52.2021.8.26.0530 - 155/21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2040228/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 774/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN HENRIQUE PEREIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

KAUAN HENRIQUE PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, "caput", Lei Nº 11.343/2006 e art. 329, "caput", ambos c/c art. 61, "caput", II, "j" c/c Art. 69, "caput", todos do(a) Código Penal, porque, segundo a acusação, na data de 11 de fevereiro de 2021, por volta da 10:50 da noite, na Avenida Monteiro Lobato, cruzamento com a Rua José Veríssimo, na Praça Centenário nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto/SP, durante a pandemia gerada pelo novo coronavírus (COVID-19), ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, as seguintes substâncias entorpecentes 64 (sessenta e quatro) cápsulas de cocaína, 8 (oito) porções de maconha e quantia de R\$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado em seu bolso.

Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020 e do Comunicado CG 232/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o acusado

teve a prisão em flagrante relaxada (pp. 53/54).

A denúncia foi recebida em 15 (quinze) de março de 2021 (p.93) e o réu foi regularmente citado (p.111) e ofertou defesa preliminar (p. 116-117).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia, reforçou a aplicação de maus antecedentes na primeira fase, bem como a agravante de reincidência e atenuante da menoridade penal na segunda fase e o afastamento da causa de diminuição do art. 33 parágrafo quarto da Lei 11.343/06, pela reincidência.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado para o tráfico de drogas (caput, 11.343/06) e para resistência (art. 329, caput, CP) com base no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo penal; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; o afastamento da agravante da calamidade pública; a aplicação da causa de diminuição estabelecida no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; além da concessão do regime menos gravoso para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Procede em parte o presente pedido.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (pp.1), auto de exibição e apreensão (pp.6-7), fotos dos entorpecentes (pp.8-10), laudo pericial de constatação (12-14), boletim de ocorrência (pp.15-17), exame químico toxicológico (pp.80-82), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, os policiais militares André Caetano Bianchi e Rodrigo Fatarelli narraram de forma harmônica que estavam em patrulhamento preventivo pela praça centenário (p. 76) - já conhecido ponto de tráfico - quando se depararam com o réu que, ao perceber a presença da viatura, jogou uma sacola plástica no chão e começou a correr. Quando alcançado, o acusado resistiu à abordagem, razão pela qual foi necessário uso de força moderada para algemá-lo.

Na busca pessoal, foram encontradas em sua posse 33 (trinta e três) cápsulas de cocaína, além de 8 (oito) porções de maconha e a quantia de R\$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Posteriormente, os policiais se deslocaram até o local onde Kauan dispensou a sacola, onde encontraram 31 (trinta e uma) cápsulas de cocaína embaladas de forma semelhante às achadas em seu bolso. Acrescentaram que o réu já havia sido abordado em ocasiões anteriores, visto que havia denúncias que apresentavam suas características físicas, contudo, não foram encontrados entorpecentes sob sua posse.

Por fim, os depoentes afirmaram que, quando indagado, o acusado negou a propriedade das drogas e o respectivo tráfico.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito ora em análise. Asseverou que tinha o costume de comprar e utilizar entorpecentes na praça, sendo que também frequentava o local para trabalhar como chapeiro em um carro de lanches localizado na esquina da praça. Confirmou que foi abordado em outras ocasiões, porém em nenhuma delas estava com entorpecentes.

Acrescentou que, no dia em questão, foi trabalhar como chapeiro e deu 5 (cinco) reais para um menino que vendia entorpecentes no local. Quando o adolescente subiu para outra parte da praça, os policiais começaram a correr atrás do interrogando e, como já tinha sofrido outras abordagens violentas pelos mesmos policiais, correu com medo de sofrer agressões. Assim, quando chegou a um lugar movimentado com um número significativo de pessoas, parou de correr e não resistiu à prisão, afirmando que não estava com nenhum entorpecente.

Embora o réu tenha negado a prática delitiva, não há dúvidas quanto à sua responsabilidade no tocante ao tráfico, pois sua negativa se encontra isolada no conjunto probatório.

Os policiais militares foram completamente coerentes e harmônicos na descrição dos fatos, confirmando em juízo o que já haviam declarado em sede policial (p.2-3), isto é, que foram encontradas drogas tanto na posse do réu quanto na sacola por ele arremessada.

Certo é que, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos,

a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam. E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do réu, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos. Dessa forma, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções, a presunção relativa de agir de forma escorreita.

Há de se ressaltar, também, que, ainda que tenha havido pequenas dissensões entre os depoimentos dos policiais, consistentes em detalhes da diligência policial, tal fato não tem o condão de desprestigiar os testemunhos prestados. Primeiro, porque o cerne da questão foi harmoniosamente narrado por eles, sob o crivo do contraditório. Segundo, porque é indiscutível a atuação dos policiais em inúmeras diligências, sendo razoável que se esqueçam ou se confundam em relação a alguns detalhes, sobretudo porque a mente humana tem um poder muito grande de esquecimento e abstração.

Afora isso, não provou a defesa que os depoimentos dos policiais militares não retrataram a realidade, sendo que nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos coerentes prestados pelos policiais.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em seus elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada, visto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato trazer consigo a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

No que tange à aplicação da causa de diminuição disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é incontroverso, na doutrina e na jurisprudência, que os requisitos estabelecidos são cumulativos para sua aplicação, ou seja, que para a incidência dessa minorante é preciso que o agente, seja primário, detenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Com efeito, não é possível a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de agente reincidente (p.34-35). Em conformidade, destaco:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da prova, quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssomos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de amparados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do crime de tráfico de drogas, sendo incabível sua exclusão ou diminuição abaixo do patamar legal, quando inexistentes causas de diminuição. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1348951, 00047974920208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021)

Ademais, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e para afastar a incidência da causa especial de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois não há dupla valoração da reincidência. Nesse sentido é a seguinte decisão do STF:

[...] A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem [...] (RHC 121598, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, 79 MENDONÇA; CARVALHO (2008, p. 111). CAPÍTULO 2 285 PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014).

Outrossim, entendo ser o caso de afastar a circunstância agravante relativa à prática do crime durante o estado de calamidade pública (art. 61, II, "j", CP), uma vez que o crime foi cometido no dia 11 de fevereiro de 2021, isto é, depois de encerrada a vigência do estado de calamidade pública, segundo dispõe o Decreto Legislativo nº 6/2020.

Verifica-se, então, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Afora isso, vale dizer que nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os depoimentos coerentes prestados em juízo, a respeito da realidade retratada, ou que pudesse afastar o decreto condenatório. Assim, o quadro probatório é suficiente para embasar a decisão condenatória.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova

suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

No tocante ao delito resistência (disposto no art. 329 do CP) presente na denúncia, imperioso ressaltar que o tipo penal delimita a ação de se opor à execução de ato legal mediante violência ou ameaça contra funcionário no cumprimento de seu dever. Tal fato, porém, não foi comprovado em juízo e tampouco pelo laudo pericial acostado aos autos (p.72-73). Conforme o depoimento policial, Kauan não empregou força física ou ameaças contra eles, apenas fugiu e não colaborou com a prisão. Trata-se, portanto, de mera oposição à abordagem dos policiais. Com efeito, sendo indispensável ação ativa para a configuração do crime de resistência, reconheço a atipicidade da conduta e absolvo o réu com base no artigo 386, inciso III, do CP. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUGA. VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. A caracterização do delito de resistência (CP, art. 329) depende do emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público que pratica o ato legal. 2.1. Na hipótese em que o agente tenta se evadir da prisão em flagrante, não se pode presumir que, pelo fato dos policiais terem apresentado lesões, o Réu tenha dolosamente empregado violência contra eles, notadamente quando declaram em juízo que não foram agredidos. 3. O art. 44, § 2º, do CP confere certa discricionariedade ao magistrado no momento da substituição da pena privativa de liberdade aplicada em patamar superior a 01 (um) ano, o qual pode optar por 01 (uma) pena restritiva de direitos e multa ou por 02 (duas) restritivas de direitos. Não é conferida ao condenado a possibilidade de optar pelo que lhe parece mais vantajoso ou menos prejudicial. 4. Recursos não providos. (TJ-DF 00080788120188070001 DF 0008078-81.2018.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 30/07/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante aos valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União, na forma do art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP.

Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas como as normais do tipo e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprovam as certidões de folha de antecedentes (p.34-35). Entretanto, reconheço a atenuante da menoridade relativa. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Acrescenta-se que o réu é reincidente e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e CONDENO KAUAN HENRIQUE

PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Faculto o direito a recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 118).

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos valores apreendidos, eis que comprovadamente oriundos do tráfico.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA